

1500403-67.2021.8.26.0612

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500403-67.2021.8.26.0612 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500403-67.2021.8.26.0612

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2347573/2021 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 22080872 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2807/21/917 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2347573 - 01º D.P. JABOTICABAL, 2807/21/917 - 01º D.P. JABOTICABAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO MARQUES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

FÁBIO MARQUES, CARLOS RODRIGUES DE ARAÚJO e LUANA VILCHES CARDOSO DA SILVA foram denunciados e estão sendo processados pelo Ministério Público como incursos nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de Drogas, na forma do artigo 69 do Código Penal, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, 21 de dezembro de 2021, por volta de 22h00, na Rua Narciso Mendes Ferreira n. 51, bem como na Rua Vicente Palazio, n. 18, ambos neste município e comarca de Jaboticabal/SP, o acusado Fábio, "Vulgo "Galinha", o acusado Carlos e a acusada Luana guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 74 (setenta e quatro) invólucros plástico, do tipo "filme, contendo Cannabis sativa, L (maconha), com massa líquida de 803,32g (oitocentos e três gramas e trinta e dois centigramas); 56 (cinquenta e

seis) microtubos contendo Cannabis sativa, L (maconha), com peso líquido de 7g (sete gramas); 10 (dez) tijolos de Cannabis sativa, L (maconha), com massa líquida de 7,3kg (sete quilos e trezentos gramas); 138 (cento e trinta e oito) cápsulas contendo "cocaína", com peso líquido de 59,6g (cinquenta e nove e seis gramas); 01 (um) invólucro plástico, fechado por nó, contendo "cocaína", com massa líquida de 633,79g (seiscentos e trinta e três gramas e setenta e nove centigramas), além de 86 (oitenta e seis) comprimidos da substância entorpecente 3,4

Metilenodioximetanfetamina (MDMA) - ecstasy - pesando 38,13g (trinta e oito gramas e treze centigramas). Tais entorpecentes causam dependência física e psíquica. Houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos acusados Fábio e Carlos, no dia 22 de dezembro de 2021 (fls. 77/81)

Os três acusados foram notificados (fls. 180, 182 e 185) e apresentaram defesa prévia (fls. 202/208, 216/218 e 221).

A denúncia de fls. 149/153 foi recebida dia 18 de abril de 2022 (fls. 222/224), designando, nesta mesma oportunidade a audiência de instrução e julgamento.

Os acusados foram citados.

Durante a instrução, foi colhida prova oral e, ao final, os acusados foram interrogados.

Ao final, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a absolvição dos três acusados, tendo em vista a ilicitude de toda a prova obtida nos autos.

As Defesas de Fábio, Carlos e Luana ratificaram a manifestação do douto

Representante do Ministério Público, pugnando, em síntese, também pela absolvição. É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente registre-se que, com relação à materialidade delitiva, vieram aos autos os seguintes elementos de prova: auto de prisão em flagrante dos acusados Fábio e Carlos (fl. 01); boletim de ocorrência (fls. 08/11); auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e materiais que auxiliam a prática do tráfico de drogas (fls. 18/19 e 20/21); imagem dos entorpecentes apreendidos e seus respectivos pesos (fls. 28/34); laudo pericial das peças apreendidas no contexto dos fatos com anexos fotográficos, constatando vestígio de drogas (fls. 118/125); laudo de exame químico-toxicológico positivo para as substâncias entorpecentes (fls. 126/128, 129/131 e 132/134); relatório final (fls. 141/144).

Ocorre que, a par disso, a prova oral colhida em audiência trouxe o seguinte delineamento:

A testemunha Cairo Augusto Carmociano da Silva, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento, passando em frente à casa de Luana (que sabiam que ela era envolvida com tráfico), quando viram Carlos em frente a tal casa. Entraram no quintal da casa e em uma geladeira nos fundos encontraram maconha, e dentro da casa outras drogas, bem como faca com resquício de drogas, balança e outros petrechos. Disse que Luana não estava presente, só estava Carlos. Já na casa que sabiam ser de Carlos, para onde foram em seguida, estava Fábio. Nessa casa encontraram o restante das drogas, petrechos, balanças de precisão e uma mochila do ifood que eles utilizaram para disfarçar as entregas de drogas. Disse que sabiam que Carlos era envolvido com tráfico. Carlos confessou que a droga era dele, que ele guardava na casa da Luana. Disse que fazia as entregas juntamente com entregas como mototaxista do ifood. O Fábio também falou que fazia a entrega de delivery, utilizando as viagens para vender as drogas.

A testemunha Adriano José Trindade, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento próximo à residência da Luana (sabiam que ela morava lá via denúncias e que era envolvida no tráfico). Ela não estava lá, mas viram quando Carlos estava saindo da residência dela. Em abordagem, ele admitiu que no fundo da residência havia drogas, que a Luana guardava para ele. Na geladeira encontraram os tijolos de maconha, além de ecstasy e outros petrechos. Já na casa de Carlos encontraram Fábio, que contou que ali também tinha drogas. Disse que fazia delivery de drogas para Carlos, em troca de dinheiro, utilizando-se para tanto a mochila do ifood. Disse que Carlos não os acompanhou até a segunda casa, que ele foi em outra viatura, diretamente para a Delegacia.

A testemunha de defesa Ricardo Querino Ferreira disse que Carlos reside com seus pais, em frente à casa da testemunha.

Em interrogatório, a acusada Luana Vilches Cardoso da Silva negou a prática delitiva. Desconhecia a existência dessa droga em sua casa. Deixou apenas Carlos ficar em sua casa por alguns dias. Confirmou que a primeira casa onde foram encontradas as drogas é sua.

Em interrogatório, o acusado Carlos Rodrigues de Araújo disse que bateu palmas na casa de Luana, porque pretendia comprar drogas. Disse que sabia que lá vendiam drogas. Negou conhecer Luana. Disse que bateu palmas lá na frente, ninguém saiu, e logo os Policiais o abordaram. Disse que já tinha comprado drogas naquele local. Disse que só conhece Fábio de vista.

Em interrogatório, o acusado Fábio Marques negou a prática delitiva. Disse que a casa onde foi preso era sua e que lá só tinha 10 gramas de maconha para consumo próprio.

Pois bem. Dos testemunhos ora transcritos deflui duas conclusões:

a) a primeira casa em que os Policiais ingressaram pertencia a Luana, que não estava na residência no momento da abordagem. Assim, o ingresso no local deu-se sem a permissão da moradora e sem mandado judicial;

b) a segunda residência, que segundo os Policiais era de Carlos, foi vistoriada sem que sequer Carlos estivesse presente, pois o próprio Policial Adriano José Trindade disse, em seu depoimento em juízo, que seguiram para tal casa e que Carlos não os acompanhou, sendo levado diretamente, em outra viatura, para a Delegacia, ou seja, novamente ingresso em residência sem a presença do suposto do morador e sem a existência de mandado judicial.

Conforme previsão estampada no art. 5º, XI, da CF/88, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Logo, conclui-se que o ingresso nos domicílios dos acusados poderia ser admitido somente em três situações, são elas: i) se houvesse autorização judicial para tanto (o que não houve, no caso); ii) se houvesse consentimento válido e inequívoco do morador (também não existiu no presente caso, pois Luana sequer estava em casa e Carlos não acompanhou a diligência na segunda casa que, segundo os próprios Policiais, era o local onde ele residia); e iii) se houvesse fundadas razões concretas da ocorrência e flagrante delito no local e a urgência não permitisse a espera por mandado judicial (também não é o caso dos autos, pois havia plenas condições de solicitar-se o mandado judicial antes de ingressar nas residências). Assim, a despeito da expressiva quantidade de drogas apreendidas, a forma que estavam embaladas e os petrechos apreendidos nos locais, o fato é que toda a cadeia de provas restou prejudicada a partir do momento em que o ingresso dos Policiais nas duas residências ocorreu com inobservâncias das regras constitucionais existentes para tanto.

Está-se diante, portanto, da impossibilidade de que provas obtidas por meios ilegais amparem a prolação de uma sentença condenatória em desfavor dos acusados. Sobre o tema, a jurisprudência da 5ª e da 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu balizas para a análise de situações como a que ora se apresenta:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. [...]

2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência cuja urgência em sua cessação demande ação imediata é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade

do domicílio. 2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio justificam o retardo da cessação da prática delitiva. 2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação amiúde irreversível de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). [...] 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. 5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. 5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local. 5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada legitimar a entrada em residência ou local de abrigo. 6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio. [...] 6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção, exige-se a

indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, “necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis” (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO). 6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial ao dispor que, “[f]inda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º”. 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias não apenas históricas, mas atuais, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação como ocorreu no caso ora em julgamento de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. [...]. 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. [...] (HC 628.371/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. 0

eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). [...] (HC 616.584/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021).

Assim, diante da evidente ilicitude das provas que compõem o caderno processual, outra solução não há se não acolher as alegações finais tanto do Ministério Público quanto das defesas dos acusados e julgar improcedente a pretensão estatal punitiva. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, ABSOLVO FÁBIO MARQUES, CARLOS RODRIGUES DE ARAÚJO e LUANA VILCHES CARDOSO DA SILVA das acusações a eles imputadas na denúncia (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de Drogas), o que faço com fundamento no VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura de FÁBIO MARQUES e CARLOS RODRIGUES DE ARAÚJO, devendo ser postos imediatamente em liberdade, salvo se presos em razão de decisões proferidas em outros processos.

No tocante a Luana, verifica-se que respondeu a todo o processo em liberdade. Expeçam-se certidões aos advogados nomeados.

Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações necessárias e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Jaboticabal, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA